

1502034-52.2020.8.26.0007

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... daria vida à atividade ilegal do tráfico, e por isso sua conduta mereceria reprovação legal e responsabilização penal.

Levanta-se assim a tese de que, sem o consumo de drogas, não poderia haver o tráfico. Não se tem o objetivo de negar ou confirmar essa tese nesta decisão. É caso apenas de se discutir se, ao proteger o bem jurídico pretendido - a saúde e incolumidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-095

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1502034-52.2020.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502034-52.2020.8.26.0007

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO AUGUSTO OLIVEIRA GRANATO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

FLÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA GRANATO foi denunciado por ter, em tese, infringido o disposto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099 de 1995.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Em audiência de instrução, colheram-se as provas orais tais como seguem relatadas. Lucas de Oliveira, policial militar, testemunha de acusação, disse que estava em patrulhamento de rotina. Disse que estava próximo de uma adega e fazia fiscalização de trânsito. Afirma que o réu avistou a viatura e tentou fuga de ré. Disse que iniciou acompanhamento, até conseguir abordagem. Disse que as pessoas que estavam no carro demoraram a descer e resistiam à abordagem, que estavam visivelmente embriagados e xingaram os policiais. Afirma que, no momento da vistoria, do veículo, um dos passageiros que estava no banco de trás, estava rasgando os papелotes de cocaína e jogando fora o conteúdo, e que por isso só restaram nove papелotes de cocaína. Afirma que o uso de algemas foi necessário. Também disse que os papелotes estavam dentro de uma sacola debaixo do banco do carro. Afirma que, no

momento da abordagem, o réu admitiu ter feito uso de álcool e cocaína. Rodrigo Passarelli Domingues, policial militar, testemunha de acusação, disse que estava em patrulhamento e que fazia orientação de trânsito nas proximidades de uma adega. Disse que fez a abordagem no veículo do réu porque viu seu veículo sair em alta velocidade. Que o abordaram e que o réu estava acompanhado de mais duas pessoas. Que não encontraram nada na revista pessoal e encontraram papelotes de cocaína numa revista do veículo. Afirma que o réu aparentava estar embriagado e que o delegado requisitou exame clínico para averiguar embriaguez. Confirmou que a cocaína estava dentro do carro. Não se lembrou de ter sido xingado pelos passageiros ou pelo réu. Disse que os passageiros e o réu desceram do carro, mas que demoraram um pouco. Que não ofereceram nenhuma resistência à abordagem. Também afirmou que não se lembra do réu ou dos passageiros se desfazerem dos papelotes. O réu, interrogado, falou que não fugiu da polícia. Disse que não reagiu aos policiais e que estava em posse das drogas. Afirma que eram três papelotes para cada, para ele e para outros dois amigos. Disse que as drogas foram encontradas nos seus bolsos. Afirma que não foi encaminhado a nenhum exame clínico e reafirmou que eram nove papelotes, quando perguntado. Descreveu ter sido abordado por apenas dois policiais, a quem não ofereceram nenhuma resistência nem desacatarem.

Em que pesem as provas orais produzidas, e a própria admissão do réu de que os papelotes de cocaína encontrados em seu carro lhe pertenciam (e que seriam consumidos por ele e mais dois amigos, que com ele se encontravam), o pedido condenatório comporta acolhimento.

Em primeiro lugar, deve-se considerar que, dada a quantidade de substância (cocaína) encontrada, o fato é atípico. O Laudo Pericial de fls. 16-18 detectou que o réu, conjuntamente com dois outros sujeitos, estava em posse de 6,4 gramas (quantidade líquida) de cocaína; tem-se, assim, que haveria algo em torno de 2,1 grama de cocaína para cada um dos sujeitos envolvidos, dentre eles o réu. Apurou-se, em audiência de instrução, que cada um deles pretendia consumir em torno de três papelotes (ou pinos) de cocaína.

Ora, o direito penal, na avaliação de condutas merecedoras de responsabilização e consequente penalização, não deve apenas avaliar a adesão abstrata do fato à norma, mas sua relevância social e significância. O Supremo Tribunal Federal tem atribuído ao princípio da insignificância um papel importante na caracterização dos tipos penais. No Habeas Corpus 96.827/RS, o Ministro Relator Celso de Mello assim estabeleceu os critérios para aferição dos vetores do postulado do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a nenhuma periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica comprovada.

Não se nega que o consumo de drogas ilícitas seja assunto sujeito a reprovações de cunho religioso, filosófico ou moral. Mas é fato que o consumo e posse de pequenas quantidades de drogas como a cocaína são atos sociais corriqueiros, em especial na vida noturna de cidades grandes. Não se nega que, do ponto de vista da saúde individual, o consumo desses papelotes de cocaína certamente trará, cedo ou tarde, consequências fisiológicas ao réu. No entanto, é de se questionar se a quantidade por ele trazida é merecedora da atenção e reprovação do direito penal, sabidamente a última ferramenta, ultima ratio do cabedal jurídico e o mais gravoso dos direitos sancionadores.

A conduta em si, neste caso, é de pouca relevância para o direito penal, vez que o réu, ao portar três papelotes de cocaína dentro de seu carro, que pretendia consumir posteriormente, praticava conduta de ofensividade social diminuta e que dispensa a rigidez do tratamento penal.

Embora formalmente típico o fato descrito na denúncia, a teor da prova referida trazida ao feito, ele não apresenta nenhuma relevância material, por absoluta incapacidade de produzir um resultado que gere qualquer ameaça à incolumidade pública.

Mais do que isso, diferentemente de decisões anteriores proferidas por este juízo, coadunamos com entendimentos recentes emanados pelo Supremo Tribunal Federal de que o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 é inconstitucional.

Assim está descrita a conduta prevista no referido artigo: "Quem adquirir, guardar,

tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas”.

Ora, a norma em questão tem como fito, pela via do direito penal, proteger a saúde pública. Parte-se do pressuposto de que o usuário de drogas, ao comprá-las e consumi-las, daria vida à atividade ilegal do tráfico, e por isso sua conduta mereceria reprovação legal e responsabilização penal.

Levanta-se assim a tese de que, sem o consumo de drogas, não poderia haver o tráfico. Não se tem o objetivo de negar ou confirmar essa tese nesta decisão. É caso apenas de se discutir se, ao proteger o bem jurídico pretendido – a saúde e incolumidade públicas –, o legislador não teria, por outro lado, violado outros direitos fundamentais do sujeito, como sua intimidade e privacidade. Neste caso, parece assistir razão ao Ministro Gilmar Mendes, que em seu relatório ao Recurso Extraordinário 635659/São Paulo, argumentou:

É sabido que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que ofende, de forma desproporcional, o direito à vida privada e à autodeterminação. O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita. Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão. E a autolesão é criminalmente irrelevante. (O grifo é nosso)

Os argumentos acima mencionados podem ser perfeitamente aplicados ao caso que ora se analisa. O réu estava em posse de pequena quantidade de cocaína e dela iria fazer uso pessoal. Não são pequenos nem deletérios os efeitos do uso dessa substância sobre o corpo e a vida do réu.

No entanto, essas ações ainda estão na alçada de sua intimidade e de seus direitos de personalidade. São incapazes de atingir, por elas mesmas, a incolumidade ou a saúde pública. A conexão do consumo de uma pequena quantidade de cocaína com todos os mecanismos do tráfico de drogas é remota, e punir o usuário por meio do direito penal torna-se excessivamente gravoso à sua intimidade e privacidade, corolários dos seus direitos fundamentais (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal). Entendendo inconstitucional a penalização do consumo e posse de drogas por usuários, entendo, assim, como atípica a conduta do réu.

Por todo o exposto, é de rigor a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO FLÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA GRANATO, da imputação prevista no art28 da Lei 11.343 de 2006 com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Proceda-se às comunicações e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA